

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2429/2551

ป.วิ.อ. มาตรา 226

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นางวิสาลักษณ์ ศิริวงศ์

โจทก์

จำเลย

สืบตำรวจตรี ส. ขอซื้อยาลดความอ้วนซึ่งมีส่วนผสมของเฟนเตอมีนจากจำเลย จำเลยบอกว่าไม่มีและที่ร้านของจำเลยไม่ได้ขายลดความอ้วนดังกล่าวสืบตำรวจตรี ส. จึงบอกว่าคนรักต้องการใช้ยาลดความอ้วน จำเลยจึงบอกว่าจำเลยมียาลดความอ้วนอยู่ 1 ชุด ที่จำเลยซื้อมาไว้รับประทานเอง สืบตำรวจตรี ส.ขอซื้อยาลดความอ้วน ชุดนั้นจำเลยจึงขายให้และเมื่อมีการตรวจค้นร้านขายยาของจำเลยก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เมื่อจำเลยไม่มีเฟนเตอมีนของกลางไว้เพื่อขายดังที่โจทก์ฟ้อง และรับฟังไม่ได้ว่าที่ร้านขายยาของจำเลยเคยมีการขายเฟนเตอมีนมาก่อน ดังนั้น การที่จำเลยขายเฟนเตอมีนของกลางให้แก่สืบตำรวจตรี ส. จึงเกิดจากการถูกล่อให้กระทำความผิด โดยจำเลยไม่มีเจตนาจะกระทำความผิดในการขายเฟนเตอมีนมาก่อน พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นพยานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบโจทก์ไม่สามารถอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 เวลากลางวัน จำเลยมีเฟนเตอมีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จำนวน 15 แคปซูล น้ำหนัก 0.549 กรัม ไว้ใน

ครอบครองเพื่อขาย และจำเลยได้ขายเฟนเตอมีนดังกล่าวให้แก่ผู้ล่อซื้อในราคา 250 บาท โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้ พร้อมธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อและเฟนเตอมีนจำนวนดังกล่าว เป็นของกลาง เฟนเตอมีนของกลางหมดไปในการตรวจวิเคราะห์ส่วนธนบัตรของกลางเจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 89

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 วางโทษจำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยและนายอัครฉัตร สามีประกอบกิจการร้านขายยาชื่อ นิวัฒนาเพิ่มสิน โดยนายอัครฉัตรได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการ ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยได้ขายยา ลดความอ้วนของกลางจำนวน 15 แคปซูล ให้แก่สืบตำรวจตรีสมเกียรติ ผู้ล่อซื้อในราคา 250 บาท ยาลดความอ้วนของกลางทั้ง 15 แคปซูล ได้มีการตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ผลการตรวจวิเคราะห์ตรวจพบเฟนเตอมีนซึ่งเป็น

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ผสมอยู่จำนวน 0.549 กรัม มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานมีเฟนเตอมีนจำนวนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อขายและขายเฟนเตอมีนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ เห็นควรวินิจฉัยตามคำแก้ฎีกาของจำเลยก่อน โดยจำเลยยื่นคำแก้ฎีกาว่าจำเลยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ายาลดความอ้วนที่จำเลยขายให้แก่สืบตำรวจตรีสมเกียรติมีเฟนเตอมีนผสมอยู่ เนื่องจากจำเลยไม่ใช่แพทย์หรือเภสัชกรจึงไม่ทราบมาก่อนว่าในยาลดความอ้วนมีส่วนผสมของเฟนเตอมีนอยู่ด้วย เท่ากับว่าจำเลยไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดปัญหานี้พันตำรวจโทมานพ พนักงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความว่า ในชั้นสอบสวนพยานแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เฟนเตอมีน) ไว้ในครอบครองเพื่อขายและขายเฟนเตอมีนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพซึ่งตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวระบุว่านายอัครฉัตร สามีจำเลยร่วมฟังการสอบสวนและได้ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกคำให้การของจำเลยด้วย และปรากฏจากบันทึกคำให้การดังกล่าวว่า จำเลยตอบคำถามพนักงานสอบสวนว่า จำเลยทราบดีว่ายาลดความอ้วนที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดไว้เป็นของกลางเป็นวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งการขายหรือมีไว้ในครอบครองเป็นความผิดจำเลยเบิกความว่าในการสอบสวนตามบันทึกคำให้การพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำจำเลยและพิมพ์ตามที่จำเลยให้การ แต่จำเลยเบิกความต่อไปว่า ที่ตอบว่าจำเลยทราบดีนั้น จำเลยไม่ทราบมาก่อนว่ายาลดความอ้วนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ เพิ่งมาทราบจากพนักงานสอบสวน เห็นว่าจำเลยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนนายอัครฉัตร สามีจำเลยจบการศึกษาระดับปริญญาโท หากจำเลยเพิ่งทราบจากพนักงานสอบสวนว่ายาลดความอ้วนของกลางเป็นวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งการขายหรือมีไว้ในครอบครองเป็นความผิดจำเลยก็ชอบที่จะให้การปฏิเสธเนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการบังคับขู่เข็ญหรือกระทำด้วยประการใดให้จำเลยให้การรับสารภาพแต่อย่างใดประกอบกับจำเลยและสามีมีอาชีพค้าขายโดย

ประกอบกิจการร้านขายยา มิใช่เป็นประชาชนทั่วไปที่เพียงแต่บริโภคยา จำเลยจึงน่าจะต้องทราบว่า ยาลดความอ้วนดังกล่าว มีเฟนเตอมีน อันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ผสมอยู่ และน่าจะต้องทราบว่า การขายหรือมิไว้ในครอบครอง ยาลดความอ้วนดังกล่าว เป็นความผิด ดังนั้น ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า จำเลยไม่ทราบว่า ยาลดความอ้วนที่จำเลยขายให้แก่ สิบตำรวจตรี สมเกียรติ มีเฟนเตอมีน อันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ผสมอยู่ จึงฟังไม่ขึ้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยรู้อยู่แล้วว่า การมีเฟนเตอมีนไว้ในครอบครอง เป็นความผิดต่อกฎหมาย จำเลยเบิกความว่า จำเลยซื้อ ยาลดความอ้วนของกลาง ทั้ง 15 แคปซูล มาจากพนักงานขายยา โดยไม่ปรากฏว่า จำเลยได้ทำตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยมิไว้ในครอบครอง ซึ่งเฟนเตอมีนของกลาง โดยมิได้รับอนุญาต ปัญหาว่า จำเลยครอบครองเฟนเตอมีนของกลางไว้เพื่อขายหรือไม่ และการกระทำของจำเลย เป็นความผิดฐานขายเฟนเตอมีน โดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันรับฟังได้ว่า ในการล่อซื้อเฟนเตอมีนจากจำเลย เมื่อ สิบตำรวจตรี สมเกียรติ ขอซื้อ ยาลดความอ้วนจากจำเลย โดยบอกว่า จะเอาไปให้คนรัก จำเลยบอกว่า ไม่มี และที่ร้านของจำเลย ไม่ได้ขาย ยาลดความอ้วน สิบตำรวจตรี สมเกียรติ จึงบอกว่า คนรักของ สิบตำรวจตรี สมเกียรติ จะต้องใช้ ยาลดความอ้วน และจะกลับไปต่างจังหวัด ในวันที่ ล่อซื้อ นั้นเอง จำเลยจึงบอกว่า จำเลยมี ยาลดความอ้วน อยู่ 1 ชุด ที่จำเลยซื้อ มาไว้รับประทานเอง สิบตำรวจตรี สมเกียรติ ขอซื้อ ยาลดความอ้วน ชุดนั้น จำเลยจึงขายให้ ในราคา 250 บาท และเมื่อมีการตรวจค้นร้านขายยาของจำเลย ก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายอื่นแต่อย่างใด ที่โจทก์ฎีกาว่า ก่อนการล่อซื้อ ได้มีการสืบทราบมาก่อนเกิดเหตุแล้วว่า จำเลยลักลอบขาย ยาลดความอ้วน นั้น แม้ สิบตำรวจตรี สมเกียรติ พยานโจทก์ จะเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุ ได้มีการสืบทราบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า ที่ร้านขายยาของจำเลย มีการลักลอบขาย ยาลดความอ้วน โดยทางกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยให้ส่งตัวอย่าง ยาลด

ความอ้วนมาให้ดูด้วย แต่โจทก์ก็ได้ส่งหนังสือหรือตัวอย่างยาลดความอ้วนดังกล่าว ต่อศาลคำเบิกความของสืบตำรวจตรัสสมเกียรติจึงเป็นคำเบิกความลอยๆ และไม่ สอดคล้องกับบันทึกการจับกุมที่ระบุว่าจากการสืบสวนเจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบ ว่าร้านขายยานิววัฒนาเพิ่มสินมีการลักลอบขายเฟนเตอมีน ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงาน ตำรวจได้เบาะแสมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่อย่างใด นางนัยนา ซึ่งรับราชการอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในตำแหน่งเภสัชกร มีหน้าที่ ตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า พยานได้ รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544 ให้ไปร่วมตรวจสอบกับเจ้า พนักงานตำรวจในวันรุ่งขึ้นโดยยังไม่ได้บอกว่าให้ไปตรวจอะไร ตามคำเบิกความของ นางนัยนาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ไม่ปรากฏว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสืบทราบมาว่าที่ร้านขายยาของจำเลยมีการ ลักลอบขายยาลดความอ้วนดังที่สืบตำรวจตรัสสมเกียรติเบิกความ ส่วนพันตำรวจโท มาณพ พนักงานสอบสวนเบิกความว่า จากการสอบสวนผู้ร่วมจับกุมซึ่งไม่ปรากฏว่า เป็นใครได้ความว่านางนัยนาได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานตำรวจว่าที่ร้านขายยาของ จำเลยมีการลักลอบขายยาลดความอ้วน ดังนั้นพยานโจทก์จึงรับฟังเอาแน่นอนไม่ได้ว่า หน่วยงานใดเป็นผู้สืบทราบและรับฟังไม่ได้ว่าก่อนการล่อซื้อจับกุมมีการสืบทราบมา ก่อนดังที่สืบตำรวจตรัสสมเกียรติเบิกความนายศักดิ์ชัย พยานโจทก์อีกปากหนึ่งซึ่ง เป็นเภสัชกรประจำอยู่ที่ร้านขายยาของจำเลยเบิกความว่า พยานไม่เคยเห็นยาลด ความอ้วนของกลางอยู่ในร้านดังนี้ พยานหลักฐานตามที่โจทก์นำสืบจึงรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยมีเฟนเตอมีนของกลางไว้เพื่อขายดังที่โจทก์ฟ้อง และรับฟังไม่ได้ว่าที่ร้านขาย ยาของจำเลยเคยมีการขายเฟนเตอมีนมาก่อน ดังนั้น การที่จำเลยขายเฟนเตอมีนข องกลางให้แก่สืบตำรวจตรัสสมเกียรติจึงเกิดจากการถูกล่อให้กระทำความผิด โดย จำเลยไม่มีเจตนาจะกระทำความผิดในการขายเฟนเตอมีนมาก่อน พยานหลักฐาน ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นพยานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ โจทก์ไม่สามารถอ้างเป็นพยาน

หลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ส่วนที่โจทก์
ฎีกาว่า จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนรับฟังลงโทษจำเลยได้นั้น เห็นว่า เมื่อ
พยานหลักฐานของโจทก์ในชั้นพิจารณารับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้เช่นนี้แล้ว ลำพังแต่
คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนก็ไม่อาจรับฟังลงโทษจำเลยได้ อย่างไรก็ตาม
ก็ตามคดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยมีเฟนเตอมีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
2 ไว้ในครอบครองเพื่อขาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ และ 89 ความผิดดังกล่าวย่อมรวมถึงกา
รมีเฟนเตอมีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง และ
106 วรรคหนึ่ง อยู่ด้วย ถือได้ว่าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่างซึ่ง
แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองเมื่อทางพิจารณาฟังได้ว่าจำเลยมีเฟนเต
อมีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิด
ฐานมีเฟนเตอมีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีบทลงโทษเบากว่าตามที่
พิจารณาได้ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรค
ท้ายได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยบางส่วน ฎีกาของโจทก์
ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง, 106 วรรคหนึ่ง วางโทษจำคุก 1 ปี
และปรับ 21,000 บาท คำให้การในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนและทางนำสืบของ
จำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน และปรับ 14,000 บาท ไม่
ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษจำคุกไว้ภายในกำหนด
1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในการล่อให้กระทำความผิดนั้น แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเยอรมันแต่เดิมศาลจะไม่ลงโทษจำเลยที่ถูกล่อให้กระทำความผิด (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด) หากการล่อให้กระทำความผิดดังกล่าวขัดต่อหลักนิติรัฐ โดยตามแนวคำพิพากษาของศาลถือว่ากรณีดังต่อไปนี้เป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐ เช่น ถ้าจำเลย (คือผู้ที่ถูกล่อให้กระทำความผิด) ยังไม่เคยถูกลงโทษมาก่อน จำเลยเป็นผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐหากว่าตัวผู้ค้ายาเสพติดเป็นผู้เข้าหาตัวผู้ล่อให้กระทำความผิดเอง (BverfG NJW 1987, 1870) นอกจากนี้คำถามของเจ้าพนักงานตำรวจที่ถามหญิงโสเภณีว่าเธอพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเคยวินิจฉัยไว้ว่าไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐ (BverfG NStZ, 1985, 131) การล่อให้กระทำความผิดที่ขัดต่อหลักนิติรัฐตามแนวคำพิพากษาศาลเยอรมันข้างต้น จะนำไปสู่อุปสรรคในการฟ้องร้องดำเนินคดีและอุปสรรคในกระบวนการพิจารณาคดี (Strfverfolgungs - und Prozesshindernis) ผลในทางกฎหมายก็คือกระบวนการพิจารณาไม่อาจที่จะดำเนินต่อไปได้ ศาลไม่อาจที่จะวินิจฉัยลงในเนื้อหาของคดีได้และต้องยุติคดีลง ในทางตรงกันข้าม แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเยอรมันในปัจจุบัน (ตั้งแต่คำวินิจฉัยของศาลในคดี BGHSt 32, 345; BGH Strv 1989, 518) เห็นว่าการล่อให้กระทำความผิดที่เป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐนั้นเป็น

แต่เพียงเหตุในการลดโทษอย่างสำคัญ ("wesentlichen Strafmilderungsgrund) และลงโทษจำเลยในอัตราโทษขั้นต่ำตามกฎหมาย ส่วนความเห็นในทางตำรานั้นยังไม่เป็นที่ยุติ บางฝ่ายเห็นไปในทำนองเดียวกันกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเยอรมันแต่เดิม ส่วนศาสตราจารย์ Roxin เห็นว่าการล่อให้กระทำความผิดที่เป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐนั้นเป็นเหตุตัดในการลงโทษซึ่งเป็นเรื่องในทางสารบัญญัติ (ein materiellrechtlicher Strafausschliessungsgrund) (ผลในทางกฎหมายก็คือยกเว้นโทษให้จำเลยนั่นเอง) ไม่ใช่เรื่องอุปสรรคในกระบวนการพิจารณาคดี (kein Prozesshindernis) เพราะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขัดต่อหลักนิติรัฐนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แรกในเรื่องของกระบวนการพิจารณาแต่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกในเรื่องของการเกิดขึ้นของการกระทำความผิดและด้วยเหตุนี้เอง ศาสตราจารย์ Roxin จึงเห็นว่ารัฐจึงไม่มีสิทธิลงโทษจำเลยในกรณีดังกล่าว (Vgl. Roxin, Strafverfahrensrecht, 25.Auflage 1998, บทที่ 10, หัวข้อ 27f.) คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุ เป็นไปตามแนวเดิมที่ศาลฎีกาเคยวางหลักไว้ว่าถ้าจำเลยถูกล่อให้กระทำความผิดแล้วพยานหลักฐานดังกล่าวรับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ ซึ่งดูเหมือนจะต่างกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาของเยอรมันในปัจจุบันที่เห็นว่าการล่อให้กระทำความผิดเป็นแต่เพียงเหตุลดโทษ ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่าหลักที่ศาลฎีกาของไทยวางไว้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะรัฐไม่น่าที่จะสามารถลงโทษจำเลยที่ถูกล่อให้กระทำความผิดได้ทั้งนี้เป็นไปตามหลักที่ว่ารัฐไม่อาจที่จะลงโทษบุคคลที่การกระทำความผิดของเขาเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นของรัฐได้ (venire contra factum proprium) สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ หมายเหตุ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาในเรื่องการล่อให้กระทำความผิดมีเส้นแบ่งแยกอยู่ที่ว่า พยานหลักฐานที่ได้มาจากการล่อให้กระทำความผิดนั้นเป็นพยานหลักฐานที่จำเลยมีอยู่แล้วหรือว่าเป็นสิ่งที่จำเลยทำให้มีขึ้นมาใหม่ ดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่จำเลยมีพยานหลักฐานนั้นอยู่แล้ว เช่น มีเมทแอมเฟตามีนอยู่ในความครอบครองแล้วเจ้าพนักงานไปล่อซื้อได้มา ก็ถือว่าเมทแอมเฟตามีนนั้นเป็นพยาน

หลักฐานที่ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 266 แต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเลยไม่มีเจตนากระทำความผิดมาก่อนดังเช่นข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2429/2551 เมื่อเจ้าพนักงานไปล่อซื้อ จำเลยจึงไปแสวงหาเฟนเตอมีนของกลางมา ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าเฟนเตอมีนของกลางเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบตามมาตรา 226 ดังกล่าว ซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมา ผู้เขียนมีความเห็นเพิ่มเติมว่า หลังจากมีการเพิ่มมาตรา 226/1 โดยผลของ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 281 พ.ศ.2551 จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงการกระทำของเจ้าพนักงานในเรื่องการไปล่อซื้อด้วย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า หลังจากที่มาตรา 226/1 มีผลบังคับใช้แล้ว การที่เจ้าพนักงานจะกระทำการล่อซื้อต้องกระทำไปโดยมีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา เป็นต้น ที่ให้อำนาจและกำหนดหลักเกณฑ์ของการที่เจ้าพนักงานจะไปล่อซื้อซึ่งส่งผลให้การล่อนั้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไข ป.วิ.อ. ให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรา 226/1 มิฉะนั้นการล่อซื้อของเจ้าพนักงานที่ไม่มีกฎหมายรองรับอาจถูกตีความว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบและส่งผลให้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการล่อซื้อเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226/1 ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช้เป็นบทตัดพยานหลักฐานที่เด็ดขาด แต่ก็ควรมีกฎหมายกำหนดให้ชัดเจนในเรื่องอำนาจของเจ้าพนักงานในการรวบรวมพยานหลักฐานว่าจะต้องกระทำอย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย พรเพชร วิชิตชลชัย